

1500137-96.2018.8.26.0673

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Favorecimento real

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 11/09/2022

... há alguns meses, pois cumpre pena por tráfico; QUE desde que Danilo foi preso a declarante o visita e nunca teve problemas; QUE já vinha a um certo tempo pensando em tentar entrar com um celular e entregar a Danilo para que ele vendesse lá dentro do presídio; QUE nunca falou tal idéia para Danilo; QUE assim, acabou comprando um micro celular em um camelô de sua cidade e na data de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Gerson Veronese Ferracini, 184, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500137-96.2018.8.26.0673 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500137-96.2018.8.26.0673

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Favorecimento real

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDA GABRIELA BESERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A acusação é procedente.

A autora do fato FERNANDA GABRIELA BESERRA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 349-A do Código Penal, porque, no dia 05 de maio de 2018, ingressou com um aparelho telefônico de comunicação móvel no interior da Penitenciária de Flórida Paulista, sem autorização legal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 03), laudo pericial (fls. 08/10),e, pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre a acusada.

A testemunha de acusação Elaine Sofia Sasso Lima , asseverou: "que é Agente Penitenciária e no dia percebeu pela imagem que a acusada estaria portando algo. Ato contínuo foi confirmado e a ré retirou o objeto da sua genitália, entregando o

celular”.

A ré não compareceu sendo decretada a sua revelia

Contudo, ouvida em sede policial, a acusada confessou os fatos: “é convivente da pessoa de Danilo Lennon Eleutério de Freitas, o qual está recolhido na Penitenciária desta cidade, isso há alguns meses, pois cumpre pena por tráfico; QUE desde que Danilo foi preso a declarante o visita e nunca teve problemas; QUE já vinha a um certo tempo pensando em tentar entrar com um celular e entregar a Danilo para que ele vendesse lá dentro do presídio; QUE nunca falou tal idéia para Danilo; QUE assim, acabou comprando um micro celular em um camelô de sua cidade e na data de hoje embalou tal aparelho e o introduziu em seu órgão genital, sua vagina; QUE ao passar pelo scanner da Unidade Prisional, funcionárias perceberam que a declarante estava portando algo; QUE foi questionada se estava com algo em seu corpo, onde na primeira vez negou, mas na segunda já afirmou que estava com um micro celular; QUE retirou tal objeto e entregou a funcionária; VOLTA a afirmar que seu convivente Danilo não sabia que a declarante faria tal coisa, ou seja, que entraria com devido objeto.”

Como se infere dos elementos coligidos aos autos, a materialidade do fato bem como sua autoria restou bem comprovada, sendo a condenação medida de rigor.

O delito previsto no art. 349-A, diante de sua natureza, tem por finalidade coibir o ingresso de aparelho telefônico móvel, rádio ou similar, em estabelecimento prisional, penalizando as condutas antecedentes ao efetivo porte ou utilização do aparelho eletrônico pelo preso, conforme se depreende do dispositivo:

“Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”

Dentre as condutas previstas no referido dispositivo legal, a denúncia retrata que a acusada promoveu a entrada do aparelho celular na unidade prisional.

A respeito da do assunto leciona Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Análise do núcleo do tipo: ingressar (dar entrada de algo em algum lugar), promover (propiciar, dar causa a algo), intermediar (colocar-se entre duas pessoas, servindo-lhes de ponte ou ligação), auxiliar (dar ajuda ou socorro) ou facilitar (torar mais fácil, favorecer) são as condutas alternativas previstas. Os verbos promover, intermediar, auxiliar e facilitar podem ter por objeto a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel (celular), de rádio ou similar. O verbo ingressar significa, em verdade, levar consigo o aparelho para dentro do presídio, o que não deixa de ser uma forma de promover a entrada do referido aparelho” (Código Penal Comentado. Editora RT. 11ª Edição, p. 1264).

No caso se entende que o dolo seja específico, isto é, deve haver vontade livre e consciente de viabilizar a comunicação do condenado com o mundo exterior, a sua concretização é irrelevante para a consumação do tipo por se tratar de crime formal, consumando-se com a simples entrada do citado objeto no interior do estabelecimento prisional.

A não concretização do intento do agente, por motivos alheios a sua vontade, implica a incidência do instituto da tentativa, previsto no artigo 14 do Código Penal.

O simples fato da ré esconder o aparelho em seu corpo demonstra sua intenção de promover a entrada de aparelho celular no estabelecimento carcerário, afigurando-se presente o elemento subjetivo do tipo.

Não há que se falar na hipótese de tentativa do delito, na forma do artigo 14, II do Código penal que dispõe:

“Art. 14 Diz-se o crime: (...) II tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa - Parágrafo único: Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”.

A respeito do assunto, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“(...) Conceito de crime tentado: é a realização incompleta da conduta típica, que não é punida como crime autônomo. Como diz Aníbal Bruno, é a tipicidade não

concluída. O Código Penal não faz previsão, para cada delito, da figura da tentativa, embora a grande maioria comporte a figura tentada. Preferiu-se usar uma fórmula de extensão, ou seja, para caracterizar a tentativa de homicídio, não se encontra previsão expressa no art. 121, da Parte Especial. Nesse caso, aplica-se a figura do crime consumado em associação com o disposto no art. 14, II, da Parte Geral." (Op. Cit., p. 182).

No presente caso, a Agente Penitenciária somente percebeu que a ré trazia consigo o aparelho celular quando esta passava pelo detector de metais, ou seja, já estava no interior da Penitenciária.

Não há como acolher a tese de atipicidade pela imprestabilidade do aparelho celular, vez que na observação, constou que o objeto poderia ser utilizado como aparelho de telefonia móvel, com capacidade para acoplar de chip. Ademais a ré confessou a prática do crime na seara policial.

O fato do aparelho já se encontrar dentro do estabelecimento penal quando foi localizado, é irrelevante para a consumação do crime o local exato, já que se trata de crime formal, o qual se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo.

Inexiste também a possibilidade da hipótese de "crime impossível", pois a existência de rigorosos sistemas de revistas ou de bloqueadores de sinal não torna impossível o ingresso de aparelhos nos presídios.

Nenhum sistema é infalível, ante a criatividade de criminosos. Os bloqueadores e aparelhos de raios-X já foram "burlados" em todo o mundo. Afigurando-se, portanto, plausível a falibilidade do sistema.

Ainda, o fato do aparelho se encontrar sem chip não descaracteriza o delito, haja vista a possibilidade de ser introduzido qualquer chip nos aparelhos e eles funcionarem.

Somente a absoluta impropriedade do aparelho para a comunicação é que afastaria a tipicidade do delito, não sendo a hipótese dos autos.

O crime previsto tipo penal em questão é de perigo abstrato, o qual não exige que o aparelho tenha capacidade de funcionar ou não para a sua configuração.

Sendo a prática do delito previsto no artigo 349-A do Código Penal, e uma vez presentes a tipicidade objetiva (fato descrito em lei) e a tipicidade subjetiva (dolo animus furandi), não concorrendo em favor da ré causas excludentes de antijuridicidade e culpabilidade, de rigor sua condenação, na forma descrita na denúncia.

Analisada a conduta, passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, verifico que a ré não possui antecedentes (FA - fls. 23), portanto é primária, e não demonstra grau de culpabilidade superior àquele considerado como próprio do tipo penal em que sua conduta é enquadrada.

Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como da sua conduta social.

Em relação aos motivos, circunstâncias e consequências do delito, nada se mostra desfavorável à ré, motivo pelo qual fixo a pena base no patamar mínimo, 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Portanto, fixo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.

O regime de início de cumprimento da pena, considerando o disposto no artigo 33 do Código Penal, será o aberto.

Pelos mesmos motivos e pela quantidade de pena aplicada, observando o disposto no artigo 44 § 2º do CP, é cabível a concessão dos benefícios previstos, portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do pagamento que deverá ser depositada em conta judicial em favor das entidades assistenciais cadastradas neste juízo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para condenar FERNANDA GABRIELA BESERRA, RG: 55164939-SP, como incurso na pena do artigo 349-A do Código

Penal, ao cumprimento de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída na forma do artigo 44 do Código Penal, conforme acima estipulado, ou seja, em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do pagamento, destinadas as entidades assistenciais cadastradas perante este juízo. Tendo em vista o regime de início de cumprimento de pena fixado, bem como a inexistência de motivos para a prisão preventiva, concedo à sentenciada o direito de recorrer em liberdade (artigo 387, §1º, CPP), ressalvada a hipótese de estar presa por outra imputação.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, expeça-se Mandado de Prisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo;

2) Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado, no valor máximo previsto na tabela do convênio celebrado entre OAB/DPE e;

3) Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal.

Isento de custas neste primeiro grau de jurisdição, de acordo com art. 54 e 55 da lei 9.099/95.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.

Florida Paulista, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA